

1502139-39.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... nos autos de que ele se dedicava ao tráfico de drogas. O adolescente mencionou na polícia que procurou os réus porque eles estavam aliciando agentes para o tráfico de drogas. Ele disse, ainda, que soube disso por outros meninos de sua rua. Sendo o réu pessoa notoriamente envolvida com o tráfico de drogas, mais especificamente com a arregimentação de traficantes, é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502139-39.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502139-39.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

GABRIEL RODRIGUES DOS REIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DOS REIS e LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, combinado com 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 18 de setembro de 2021, às 14h33, na Rua Tilápia, 38, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente Jonathan Vítor da Silva Zeferino, guardavam e mantinham em depósito para entrega ao consumo de terceiros 189 eppendorfes de cocaína, 50 porções de cocaína, 169 pedras de crack, 72 porções de maconha e 30 frascos de skunk, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 19 de setembro de 2021 (fls. 48/49).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 9/10), assim como o laudo de constatação, por fotografias (fls. 28/32) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 92/95).

Os(As) ré(s) foram notificados(as) (fls. 98 e 103) e apresentaram defesa preliminar (fls. 105/107). Em 29 de março de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 108). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) ré(s) (fls. 116/117).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 123/126 e 132/135).

É o relatório. Decido.

Os(As) ré(s)us) GABRIEL RODRIGUES DOS REIS e LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 18 de setembro de 2021, às 14h33, na Rua Tilápia, 38, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente Jonathan Vítor da Silva Zeferino, guardavam e mantinham em depósito para entrega ao consumo de terceiros 189 eppendorfes de cocaína, 50 porções de cocaína, 169 pedras de crack, 72 porções de maconha e 30 frascos de skunk, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram os réus e o adolescente, perto de uma área de lazer. Com a aproximação da viatura o grupo se dispersou, e ante a suspeita foi realizada a abordagem, ao que o adolescente disse que os réus lhe haviam proposto que atuasse no tráfico de drogas e indicou aos guardas civis onde estavam ocultos os entorpecentes acima discriminados, além de R\$ 26,00.

Interrogados em juízo, o réu Gabriel confessou a prática do crime, assim como havia feito na fase policial. Mas ele inocentou o corréu Lucas, que, segundo ele, apenas o fazia companhia no momento, não colaborando com o tráfico de drogas.

Essa versão dos fatos apresentada pelo réu Gabriel, claro, contou com a confirmação do corréu Lucas, que se manifestou em juízo no sentido de que veio da Bahia e passou a residir com o réu Gabriel. Na data do fato foram até a casa do tio de Gabriel para cortar os cabelos, no local encontrou uma mulher e ficou tomando cerveja com ela. Estava sentado na calçada quando os guardas civis chegaram. Não viu as drogas serem encontradas.

Uma vez que o réu Gabriel confessou que estava traficando, a prova do tráfico com relação a ele é importante, mas não tão importante assim como se dá com relação ao réu Lucas, que negou a prática do crime.

Na espécie, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu Lucas praticou o crime de tráfico de drogas. Embora haja elementos de prova que não lhe são favoráveis, sob o crivo do contraditório, restou razoavelmente duvidoso o envolvimento dele com o tráfico. As provas coligidas aos autos apenas confirmaram, indubitavelmente, que o réu Gabriel praticou o crime de que é acusado.

O adolescente Jonathan, abordado com os réus, prestou depoimento na fase policial. Segundo ele, não conhecia os réus, mas soube pelo pessoal de sua rua que os dois estavam procurando pessoas para atuar no tráfico de drogas. Essas mesmas pessoas entraram em contato com os réus e eles mandaram um carro de aplicativo buscar o adolescente. Estava conversando com eles sobre o comércio de entorpecentes quando os guardas civis chegaram. Um cão farejador encontrou drogas, mas o depoente não as viu até então (fl. 06).

Cuida-se de peça informativa importante, mas que não foi confirmada sob o crivo do contraditório. Ele não foi ouvido em juízo. Talvez não pudesse sê-lo, se praticou crime, pois não seria testemunha, mas corréu, apenas respondendo ao processo em juízo próprio, da infância e juventude. Nessa hipótese, poderiam ser juntadas aos autos peças do processo da infância e juventude, mas isso não foi requerido. Caso o adolescente estivesse apenas na fase de cogitação, não teria praticado ato infracional algum, de tal maneira que poderia ser ouvido como testemunha. Também não ocorreu isso.

O depoimento do adolescente, portanto, prestado apenas na fase de investigação, é de segunda importância, pois não é prova propriamente dita.

Isso poderia ser desprezado se os guardas civis tivessem prestado depoimento demonstrando que não apenas o réu Gabriel, mas também o corréu Lucas, nitidamente estava traficando, quando ambos foram avistados, abordados e presos. Contudo, os depoimentos que eles prestaram não têm essa força.

Foi ouvido em juízo apenas um dos guardas civis que efetuou a diligência. Ele confirmou o que o colega havia dito na fase de investigação, por isso se trata de depoimento bom e convincente. Mesmo assim, fica claro que os fatos, no que diz respeito ao réu Lucas, não necessariamente mostram que ele estava traficando.

Os dois guardas disseram, nas duas fases da persecução penal, que durante o patrulhamento viram dois homens e um rapaz mais jovem, juntos, na rua. O grupo

pareceu se dispersar com a aproximação da viatura e realizaram a abordagem. O adolescente disse que os dois réus se dispuseram a mostrar a ele como era feito o tráfico de drogas. Um dos réus também admitiu desde logo o envolvimento com o tráfico. Acionaram o canil, mas antes que chegasse o reforço o adolescente indicou o ponto onde estavam guardadas as drogas, perto dos réus. Numa sacola encontraram centenas de porções de drogas variadas e pequena quantia em dinheiro. Depois de serem encontradas as drogas os dois réus acabaram admitindo que eram suas. Não foram encontradas drogas com quaisquer dos réus. Havia apenas uma sacola com drogas perto deles, mas estar perto de ambos não significa que era de ambos. Poderia ser de um, não do outro.

Eles não foram vistos indo e voltando desse local onde estava a sacola, sobretudo o réu Lucas, cuja autoria é duvidosa. Eles também não foram encontrados com dinheiro, mormente em quantidade que denotaria origem ilícita dele.

São circunstâncias frágeis para se condenar uma pessoa à prisão. O flagrante tem esse aspecto dúbio: se um lado, é fácil e rápido, pois representa a constatação de um fato criminoso; de outro lado, por ser imediato, não permite que se avalie com mais detalhes o que ocorreu, qual o histórico dos fatos, qual seria o passo seguinte dos presos, etc. Nesse contexto, sempre há que prevalecer a presunção de inocência.

Acolho, portanto, a pretensão punitiva apenas com relação ao réu Gabriel.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de criança/ adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

É o caso dos autos, pois de acordo com o termo de fl. 6 e boletim de ocorrência na fl. 3 vários dados de qualificação do adolescente foram coletados, inclusive sua data de nascimento e número de seu documento de identidade. Ainda que o adolescente não estivesse exercendo o tráfico de drogas ou colaborando com o exercício, declarou que fora ao local para saber como funcionava o comércio disso e estava tratando disso com os réus, ou seja, estava em vias de ser aliciado para o tráfico, o que compreendo que se amolda na circunstância majorante descrita no artigo 40, VI, pois basta que a conduta envolva ou vise atingir a criança ou adolescente, desnecessário que ela pratique algum verbo nuclear de tipo definido na Lei de Drogas ou participe da prática.

O mesmo não pode ser dito em relação à causa de aumento do artigo 43, III. Constou na denúncia que a abordagem se deu perto de uma área de lazer. Não há nenhum detalhe sobre que tipo de área de lazer era essa e normalmente essa expressão refere-se a qualquer tipo de instalação pública como uma praça com pista de caminhada, brinquedos infantis do tipo playground e assemelhados, que em geral não atraem grande fluxo de pessoas. As disposições relacionadas do inciso mencionado são "sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes (...)" ; "recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza". Não há detalhamento de que o local onde se deram os fatos seja de algum desses tipos elencados pelo dispositivo. Presumindo que a referência seja a um equipamento público bem mais simples, como as que mencionei anteriormente, entendo que não deve incidir a causa de aumento. O STJ possui jurisprudência no sentido de que esse dispositivo deve ser interpretado estritamente. Se o legislador quisesse penalizar com mais rigor o traficante que atua numa praça, parque, perto de uma igreja, ou mesmo se quisesse autorizar a analogia, ele o faria, mas silenciou a respeito. Nesse sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.

QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MERCANCIA ILÍCITA COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram valoradas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que não se admite por incorrer em odioso bis in idem.

3. Ademais, a sanção básica deve ser redimensionada ao mínimo legal, pois, apesar da maior nocividade do entorpecente encontrado em poder do réu, o aumento operado mostrou-se desproporcional, sobretudo em razão da quantidade não expressiva, qual seja, aproximadamente 8g (oito gramas) de crack e 13g (treze gramas) de cocaína.

4. Na terceira fase da dosimetria, constata-se que a Corte de origem não apresentou fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena - a exemplo da falta de comprovação de atividade lícita -, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante em seu grau máximo, notadamente em virtude da reduzida quantidade de entorpecentes apreendida.

5. "Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão" (HC n. 528.851/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

6. Reduzida a reprimenda, e tendo em vista a primariedade do agente e a fixação da pena-base no mínimo legal em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é cabível na espécie a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. Recurso parcialmente provido." (REsp 1986321 / SP. Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Julgado em 05/04/2022)

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena verifico que o crime praticado pelo(a) ré(u) teve como objeto três espécies diferentes de drogas. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso

próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes a considerar. Estão presentes as atenuantes da menoridade de 21 anos na data do fato e da confissão espontânea, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena poderia incidir a causa de diminuição do §4º do artigo 33 porque o réu é primário, mas compreendo que existe indicativo nos autos de que ele se dedicava ao tráfico de drogas. O adolescente mencionou na polícia que procurou os réus porque eles estavam aliciando agentes para o tráfico de drogas. Ele disse, ainda, que soube disso por outros meninos de sua rua. Sendo o réu pessoa notoriamente envolvida com o tráfico de drogas, mais especificamente com a arregimentação de traficantes, é de se entender que se dedicava a tais atividades com regularidade, possivelmente integravam organização criminosa.

Por se tratar de argumento de importância secundária, isso poderia ser rechaçado para a aplicação da causa de diminuição de pena. No entanto, há outro dado que deve ser considerado e que não foi levado em conta na primeira fase: o réu tinha muita droga a sacola; 505 porções, entre maconha, cocaína e crack. É difícil imaginar que um traficante iniciante tivesse consigo drogas em tanta quantidade.

Presente, ainda, a causa de aumento do artigo 40, VI, que deve variar de 1/6 a 2/3. Não encontro motivos para fazer incidir a majorante em patamar superior ao mínimo. Vejo, inclusive, que o adolescente contava dezessete anos de idade, estando muito perto da maioridade. À míngua de fundamento para proceder de modo diverso, aumento as penas no patamar mínimo de 1/6.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) e a pena de multa, que deve seguir os mesmos parâmetros, ficam consolidadas em: 5 anos e 10 meses de reclusão; 580 dias-multa.

Sendo o réu primário e não tendo maus antecedentes, deveria iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. O tempo de detração poderia ser levado em conta para a fixação do regime aberto, mas os motivos que me fizeram rejeitar a aplicação da causa de diminuição de pena na terceira fase de aplicação da pena ora incidem para que seja mantido o regime inicial semiaberto.

Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a. Condenar o réu GABRIEL RODRIGUES DOS REIS, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06; e,

b. Absolver o réu LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA da acusação de prática do crime do artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o caso de permitir que o(a/s) ré(u/s) Gabriel recorra(m) em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do

que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.
Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.
Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.
P.R.I.C.
Barueri, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA